PUBLICACIONES DES
Centro de Pensamiento DES · Derecho · Estado · Sociedad

CLAVES DES

02 · 2026

¿Cómo elaborar un concepto de viabilidad sobre una posible costumbre mercantil?

Siete pasos para pasar de una práctica comercial observada a una investigación jurídicamente defendible

Una ruta práctica para universidades, equipos jurídicos y cámaras de comercio.

María Del Pilar Muñoz Mejía
Jennifer Vanessa Noreña Serna
Tirson Mauricio Duarte-Molina

Marco jurídico y fuentes institucionales verificadas a agosto de 2026

Centro de Pensamiento DES
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas · Universidad de San Buenaventura Cali

LA RESPUESTA

Un concepto de viabilidad no certifica una costumbre

Su función es más precisa: determinar si una práctica comercial está suficientemente formulada y jurídicamente habilitada para avanzar a una investigación de campo orientada a verificar los requisitos de la costumbre mercantil. La certificación corresponde exclusivamente a la cámara de comercio competente dentro de su jurisdicción.

CLAVE DES

El buen concepto no intenta demostrar por anticipado que la costumbre existe. Delimita la práctica, identifica el marco jurídico, descarta incompatibilidades y convierte los requisitos legales en preguntas verificables para la fase empírica.

¿Por qué importa?

Una práctica repetida entre comerciantes puede ser frecuente sin ser costumbre mercantil. Para adquirir relevancia jurídica debe superar filtros de legalidad, mercantilidad, territorialidad y evidencia. El artículo 3 del Código de Comercio exige que la práctica no contradiga la ley y que sea pública, uniforme y reiterada; el Decreto 1074 de 2015 añade, para la investigación de las cámaras de comercio, la generalidad. La conciencia de obligatoriedad y la vigencia se verifican metodológicamente para establecer si el comportamiento opera como regla del sector.

El mapa jurídico mínimo

Norma	Qué aporta al análisis
Código de Comercio, art. 3	Autoridad de la costumbre; no contradicción de la ley; publicidad, uniformidad y reiteración; referencia territorial.
Código de Comercio, arts. 4 y 5	Preferencia de estipulaciones contractuales; función interpretativa de actos, convenios y lenguaje técnico.
Código de Comercio, art. 86.5	Función de las cámaras de comercio de recopilar y certificar las costumbres de su jurisdicción.
Decreto 1074 de 2015, art. 2.2.2.38.1.4	Investigación de prácticas públicas, uniformes, reiteradas y generales, no opuestas a normas vigentes.
Código General del Proceso, art. 179	Medios para probar la costumbre mercantil nacional y su vigencia; incluye certificación de cámara de comercio.

PASO 1

Formule la práctica antes de buscar la norma

El error más frecuente consiste en iniciar el concepto con una categoría amplia -"es costumbre que los restaurantes cierren antes"- y después intentar acomodar la evidencia. El análisis debe comenzar con una conducta observable, delimitada y susceptible de ser preguntada de la misma manera a todos los integrantes del sector.

Una formulación útil responde cinco preguntas

1	**¿Quién realiza la conducta? Identifique el sector y el tipo de comerciante.**
2	**¿Qué hace exactamente? Describa la conducta sin adjetivos ni conclusiones jurídicas.**
3	**¿Frente a qué operación o relación mercantil ocurre?**
4	**¿Dónde ocurre? Delimite la jurisdicción relevante.**
5	**¿En qué condiciones o momento ocurre? Precise supuestos, excepciones y secuencia.**

Ejemplo de precisión

FORMULACIÓN DÉBIL

"Los restaurantes cierran la cocina antes de cerrar el establecimiento". No indica cuánto antes, frente a quién, con qué efecto ni cuál es la conducta jurídicamente relevante.

FORMULACIÓN OPERATIVA

"Los restaurantes con preparación activa de alimentos dejan de recibir pedidos antes del cierre general del establecimiento, destinando ese margen a procedimientos operativos y sanitarios de cierre".

La Cámara de Comercio de Bogotá reporta actualmente una práctica de este tipo dentro de las costumbres mercantiles en investigación. Su utilidad metodológica radica en que permite diferenciar el cierre de la cocina del cierre del establecimiento y convertir la conducta en una hipótesis verificable.

PASO 2

Compruebe mercantilidad, territorio y competencia

Antes de discutir si la práctica es uniforme o reiterada, debe establecerse si el comportamiento pertenece al tráfico mercantil y cuál cámara de comercio tendría competencia territorial para investigarlo y, eventualmente, certificarlo.

Tres filtros preliminares

Filtro	Pregunta jurídica	Resultado esperado
Mercantilidad	¿La conducta surge de una actividad, acto, contrato o relación de naturaleza comercial?	Identificar el vínculo con el tráfico mercantil y los sujetos que integran el sector.
Territorio	¿En qué lugar se cumplen las prestaciones o nacen las relaciones que la práctica pretende regular?	Delimitar el ámbito local o, cuando corresponda, la proyección nacional.
Competencia	¿Qué cámara de comercio ejerce jurisdicción sobre ese territorio?	Definir la entidad competente y evitar investigaciones sobre poblaciones ajenas a su circunscripción.

NO CONFUNDIR

La existencia de una práctica en redes sociales, en varias ciudades o en un gremio nacional no basta para atribuirle automáticamente alcance nacional. El concepto debe justificar la escala territorial con hechos y con la regla del artículo 3 del Código de Comercio.

Decisión al cierre del paso 2

El concepto debe poder clasificar la práctica como: (i) preliminarmente apta para continuar; (ii) apta con delimitaciones adicionales de sector o territorio; o (iii) no apta por falta de mercantilidad o por ausencia de competencia de la cámara interesada.

PASO 3

Haga el control de legalidad y determine qué función cumpliría la costumbre

La costumbre mercantil no puede desplazar una norma imperativa ni validar una práctica prohibida. El control jurídico debe estudiar todo el entorno normativo que afecta la conducta, no solo el Código de Comercio: consumo, trabajo, protección de datos, salud, competencia, contratación, seguridad o regulación sectorial pueden ser relevantes.

Tres relaciones posibles con la ley

Tipo	Qué significa	Consecuencia para el concepto
Praeter legem	La práctica opera en un espacio no regulado de manera específica.	Puede cumplir función normativa o integradora, siempre que satisfaga los demás requisitos.
Secundum legem	La práctica concreta, desarrolla o ayuda a interpretar una regla compatible.	Debe explicarse qué aspecto precisa y por qué no sustituye ni contradice la norma.
Contra legem	La práctica se opone expresa o implícitamente a una norma vigente.	No es certificable como costumbre mercantil.

ADVERTENCIA METODOLÓGICA

La metodología de la Cámara de Comercio de Bogotá incluye en la viabilidad preliminar tres controles: legalidad, ausencia de regulación y mercantilidad. Si existe regulación, el concepto njo debe detenerse en constatarla: debe establecer si la conducta pretende contradecirla, duplicarla o simplemente concretar un margen compatible. La respuesta determina la viabilidad.

Cinco preguntas de legalidad

- ¿Existe una regla imperativa que ordene o prohíba exactamente la conducta?
- ¿La práctica afectaría derechos de terceros, consumidores, trabajadores o titulares de datos?
- ¿El contrato válido entre las partes ya resolvió expresamente el punto?
- ¿La práctica pretende llenar un vacío o interpretar una regla existente?
- ¿Su certificación produciría un efecto contrario al sistema jurídico?

PASO 4

Traduzca los requisitos jurídicos en variables observables

El concepto de viabilidad debe terminar en un puente hacia la investigación. Cada requisito jurídico necesita una definición operacional y una pregunta capaz de ser respondida por los comerciantes del grupo objetivo.

Variable	Qué debe comprobarse	Ejemplo de indicador
Publicidad	La práctica es conocida por quienes participan en el sector o relación.	Conocimiento espontáneo o reconocimiento de la práctica entre comerciantes.
Uniformidad	Ante situaciones equivalentes, la conducta se ejecuta de manera sustancialmente semejante.	Proporción que describe la misma regla, condición o consecuencia.
Reiteración	No es una conducta ocasional o excepcional.	Frecuencia y permanencia temporal de la práctica.
Generalidad	La conducta se extiende de forma significativa dentro del grupo objetivo.	Cobertura de la práctica entre los integrantes del universo investigado.
Vigencia	La práctica existe actualmente.	Realización de la conducta durante un período reciente y verificable.
Obligatoriedad	Quienes la practican la perciben como regla exigible del sector, no como simple cortesía.	Respuesta sobre expectativa de cumplimiento y reacción ante su inobservancia.

UMBRAL DEL 70 %

La CCB y otras cámaras han utilizado metodológicamente un mínimo del 70 % para validar los requisitos en la fase práctica. Ese porcentaje no aparece como umbral legal en el artículo 3 del Código de Comercio: es un criterio institucional de investigación y debe identificarse como tal, no presentarse como mandato del legislador.

Frecuencia y obligatoriedad no son sinónimos. Una práctica puede ser muy frecuente y continuar siendo una simple conveniencia comercial; por eso el instrumento debe preguntar por la expectativa normativa que acompaña su ejecución.

PASO 5

Diseñe una investigación de campo que pueda defenderse

Superada la viabilidad jurídica, la pregunta cambia: ya no es "¿puede esta práctica ser costumbre?", sino "¿la evidencia demuestra que reúne los requisitos?". La calidad del concepto depende de que deje diseñada una fase empírica coherente con la hipótesis jurídica.

Ficha técnica mínima

Componente	Decisión que debe quedar documentada
Grupo objetivo	Quiénes realizan o están sometidos a la práctica; actividad económica y criterios de inclusión.
Universo	Base de comerciantes o establecimientos dentro de la jurisdicción; fuente y fecha de corte.
Muestra	Método de selección, tamaño y justificación estadística. La ley no fija un único margen de error o nivel de confianza.
Cuestionario	Preguntas neutrales, comprensibles y asociadas a cada variable jurídica; evitar inducir la respuesta.
Piloto	Prueba previa para detectar ambigüedades, categorías faltantes y tiempos de aplicación.
Trazabilidad	Registro de base, depuración, aplicación, no respuesta, resultados y decisiones de análisis.

¿PUEDE PARTICIPAR UNA UNIVERSIDAD?

Sí, como apoyo técnico o investigador. La Superintendencia de Sociedades señaló en 2024 que las cámaras pueden contratar personas naturales o jurídicas para recopilar o investigar comportamientos que puedan constituir costumbre mercantil. Sin embargo, la facultad de expedir la certificación corresponde exclusivamente a la cámara de comercio competente.

El concepto universitario debe preservar independencia técnica: puede recomendar, advertir riesgos y diseñar el estudio, pero no declarar que una costumbre existe con efectos certificatorios.

PASO 6

Redacte el concepto como una decisión de viabilidad, no como una sentencia

El documento debe mostrar el razonamiento de manera trazable: qué práctica recibió, qué normas examinó, qué riesgos encontró y por qué recomienda -o no- continuar con investigación empírica.

Estructura recomendada del concepto

#	Sección	Contenido
1	Cuestión jurídica	Formula con precisión qué debe determinarse.
2	Descripción de la práctica	Define sujetos, conducta, operación, territorio y condiciones.
3	Marco normativo y doctrinal	Identifica fuentes comerciales y regulación sectorial aplicable.
4	Análisis de mercantilidad y legalidad	Estudia competencia, función posible y relación con normas vigentes.
5	Traducción a indicadores	Convierte publicidad, uniformidad, reiteración, generalidad, vigencia y obligatoriedad en variables.
6	Diseño de campo	Propone universo, muestra, instrumento, piloto y trazabilidad.
7	Riesgos y salvaguardas	Advierte sesgos, derechos de terceros, límites y condiciones.
8	Conclusión	Clasifica la viabilidad y fija los pasos siguientes.

Tres tipos de conclusión

VIABLE

La práctica es mercantil, jurídicamente compatible y suficientemente delimitada para avanzar a estudio de campo.

VIABLE CONDICIONADA

Puede avanzar solo si se redefine el sector, territorio, formulación o control normativo antes de encuestar.

NO VIABLE

Debe utilizarse cuando la conducta es contra legem, carece de mercantilidad, está mal delimitada de forma insalvable o pretende atribuir a la costumbre un efecto incompatible con una norma imperativa.

PASO 7

Separe el concepto de la certificación y preserve la cadena de decisión

La ruta institucional concreta puede variar entre cámaras de comercio. En el modelo de la CCB, la investigación combina una fase jurídico-investigativa y una fase práctica. La viabilidad preliminar se somete a revisión, luego se desarrolla el estudio cuantitativo y, con sus resultados, se estructura la viabilidad definitiva antes de la decisión de certificación.

Ruta de referencia

1	**Solicitud o identificación de la práctica**
2	**Concepto / viabilidad jurídica preliminar**
3	**Definición del grupo objetivo e instrumento**
4	**Aplicación de encuestas y validación empírica**
5	**Análisis estadístico y viabilidad definitiva**
6	**Revisión por la instancia técnica o comité, cuando exista**
7	**Decisión de la Junta Directiva y certificación por la cámara**

VALOR PROBATORIO

Una vez certificada, la certificación de la cámara de comercio correspondiente es uno de los medios previstos por el artículo 179 del Código General del Proceso para probar la costumbre mercantil nacional y su vigencia. También existen los testimonios de dos comerciantes inscritos y decisiones judiciales definitivas dentro de los cinco años anteriores al diferendo.

La certificación no crea retrospectivamente la práctica: documenta, después de la investigación correspondiente, la existencia de una conducta que cumple los requisitos exigidos.

TEST DES

Doce preguntas antes de firmar el concepto

1	¿La práctica está redactada como una conducta concreta y observable?	☐
2	¿Los sujetos y el sector económico están delimitados?	☐
3	¿La operación o relación es de naturaleza mercantil?	☐
4	¿El territorio y la cámara competente están identificados?	☐
5	¿Se revisaron normas comerciales y sectoriales relevantes?	☐
6	¿Se descartó una contradicción expresa o tácita con la ley?	☐
7	¿Se explicó si la práctica sería praeter legem, secundum legem o inadmisible por ser contra legem?	☐
8	¿Se verificó si contratos válidos resuelven el punto que se pretende cubrir?	☐
9	¿Cada requisito jurídico fue convertido en una variable medible?	☐
10	¿El grupo objetivo, universo y diseño de campo pueden identificarse y replicarse?	☐
11	¿El documento diferencia claramente recomendación técnica de certificación oficial?	☐
12	¿La conclusión indica sin ambigüedad si la práctica es viable, condicionada o no viable?	☐

REGLA DE CIERRE

Si las preguntas 3, 4 o 6 no pueden responderse afirmativamente, el concepto no debería recomendar el inicio de la investigación empírica. La falta de mercantilidad, de competencia o de compatibilidad jurídica no se corrige con una encuesta favorable.

PARA PROFUNDIZAR

Fuentes esenciales

Colombia. Decreto 410 de 1971 - Código de Comercio, arts. 3, 4, 5 y 86. Disponible en: https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html

Colombia. Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso, art. 179. Disponible en: https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html

Colombia. Decreto 1074 de 2015, art. 2.2.2.38.1.4. Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

Cámara de Comercio de Bogotá. (2021). ABC de la Costumbre Mercantil. https://assets.ctfassets.net/n1ptkpqt763u/1PJthIujr77We8zMzFGtjq/5769917784ecf11c7d410d6325efc498/ABC_Costumbre_Mercantil_julio_2022.pdf

Cámara de Comercio de Bogotá. Costumbre Mercantil: ejemplos, beneficios e investigaciones en curso. https://www.ccb.org.co/es/tramites-y-consultas/otras-consultas/costumbre-mercantil

Cámara de Comercio de Cali. Elementos y proceso para certificar una Costumbre Mercantil. https://www.ccc.org.co/minisite-costumbre/

Superintendencia de Sociedades. (2024). Oficio 220-105698 del 7 de mayo de 2024. Funciones de las cámaras de comercio - recopilar y certificar la costumbre mercantil.

Bernal Fandiño, M., & Bonilla Rojas, M. (2023). De las costumbres mercantiles. Cámara de Comercio de Bogotá / Grupo Editorial Ibáñez.

Citación sugerida

Muñoz Mejía, M. D. P., Noreña Serna, J. V., & Duarte-Molina, T. M. (2026). ¿Cómo elaborar un concepto de viabilidad sobre una posible costumbre mercantil? Claves DES, 2. Centro de Pensamiento DES, Universidad de San Buenaventura Cali.

ALCANCE

Esta Clave ofrece una ruta metodológica de apoyo. No sustituye la metodología interna que adopte la cámara de comercio competente, ni constituye certificación sobre la existencia de una costumbre mercantil concreta.

Publicaciones DES · Centro de Pensamiento DES — Derecho · Estado · Sociedad

Las interpretaciones y recomendaciones contenidas en este documento son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la posición institucional de la Universidad de San Buenaventura Cali.